

<제4장 취소소송의 기타 소송요건.제1절 행정심판전치주의>

I. 행정심판전치주의의 의의

1. 개념[행소법 제18조 제1항]

- 행정심판전치주의라 함은 취소소송을 제기하기 전에 법률이 정한 행정심판 절차를 반드시 거치도록 강제하는 제도를 말한다. 행정소송법 제18조 제1항은 취소소송은 법령의 규정에 따라 당해 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는 경우에도 이를 거치지 아니하고 제기할 수 있다고 규정하여 임의적 전치주의를 원칙으로 선언한다.

2. 현행제도

- 현행 행정소송법 체계 하에서 행정심판전치주의는 임의적 전치주의가 원칙이다. 따라서 개별 법률에서 행정심판의 재결을 거치지 아니하면 취소소송을 제기할 수 없다고 명시적으로 규정하고 있는 경우에만 필요적 전치주의가 적용된다. 현행 제도는 국민의 권리 구제 편의성을 증진하고 신속한 재판을 받을 권리를 강화하는 방향으로 설정되어 있다.

II. 행정심판전치주의의 요건

1. 심판청구의 적법성

- 행정심판전치주의가 적용되는 경우, 취소소송의 제기 전에 청구된 행정심판은 적법한 요건을 갖춘 것이어야 한다. 즉, 청구기간 준수, 피청구인 적격 등 행정심판의 청구 요건을 구비해야 한다. 행정심판이 부적법하다는 이유로 각하재결이 나온 경우에는 원칙적으로 전치 요건을 충족하지 못한다. 다만, 심판기관이 실질적인 심리를 하여 본안에 대한 재결을 한 경우에는 설령 심판 청구가 다소 부적법했더라도 전치 요건은 충족된 것으로 본다.

2. 인적 관련성

- 행정심판 청구인과 후속 취소소송의 원고 간에 인적 동일성이 요구되는지 여부가 문제된다. 판례는 심판 청구인과 소송 원고가 엄격히 동일인일 필요는 없으며, 법률상 이익을 공유하는 관계에 있거나 사실상 동일인으로 볼 수 있는 경우에는 인적 관련성이 인정된다고 본다. 예를 들어 법인의 대표자 변경, 공동 신청인 중 1인의 심판 청구 및 다른 1인의 소송 제기 등의 경우 인적 관련성이 인정될 수 있다.

3. 사물적 관련성

- 행정심판의 대상인 처분과 취소소송의 대상인 처분은 기본적인 동일성을 유지해야 한다. 사물적 관련성은 처분의 취소 소송을 제기한 것이 심판 대상 처분의 위법성 판단을 구하는 것과 동일한 실질을 가지는지 여부로 판단된다. 다만, 처분청이 행정심판 청구 후 원처분을 변경하는 처분을 하였을 때 원고가 변경 후의 처분을 다투면서 소를 변경하는 경우에는 전치주의의 예외 규정(행소법 제18조 제3항 제2호)이 적용되어 사물적 관련성 여부와 상관없이 전치 요건이 충족된 것으로 간주된다.

4. 주장사유의 관련성

- 행정심판 단계에서 주장한 위법 사유와 취소소송 단계에서 주장하는 위법 사유가 동일해야 하는지 여부가 문제된다. 판례는 전치주의는 국민에게 행정심판 절차를 거치도록 요구하는 것에 불과할 뿐, 행정심판 단계에서 주장하지 않은 위법 사유를 소송에서 새로이 주장하는 것을 금지하는 취지까지는 아니라고 본다. 따라서 심판 단계에서 적법한 청구를 하였다면, 소송에서는 심판 단계에서 주장하지 않은 다른 위법 사유도 자유롭게 주장할 수 있다.

5. 전치요건의 충족시기

- 행정심판전치주의의 요건 충족 시기는 사실심 변론종결 시이다. 취소소송의 소송요건은 사실심 변론종결 시까지 유지되어야 하기 때문이다. 따라서 설령 원고가 소송 제기 당시 아직 재결을 받지 못했더라도, 사실심 변론종결 시까지 재결이 있다면 그 요건은 충족된 것으로 보아 적법한 소송이 된다. 이는 국민의 권리 구제 기회를 확대하기 위한 조치이다.

III. 행정심판전치주의의 적용범위

1. 항고소송의 종류와 적용범위[행소법 제38조 제2항·제1항]

- 행정심판전치주의를 규정한 행정소송법 제18조는 취소소송에 관한 규정이다. 행정소송법 제38조 제1항은 무효등 확인소송에 대하여 취소소송의 규정을 준용하도록 하고 있으나, 동조 제2항은 제18조 등 일부 규정을 무효등 확인소송에 명시적으로 준용하고 있지 않다. 따라서 취소소송과 부작위위법확인소송(제18조를 명시적으로 준용하지 않지만 제20조를 준용하고 있어 의무이행심판을 전치한다)에 한하여 전치주의가 적용되며, 무효등 확인소송에는 전치주의가 원칙적으로 적용되지 않는다.

2. 예외적인 개별법상 필요적 전치주의[국세기본법 제56조 제2항, 국가공무원법 제16조 제1항, 교육공무원법 제53조 제1항, 도로교통법 제142조]

- 행정소송법의 임의적 전치주의 원칙에도 불구하고, 개별 법률에서 특정 처분에 대하여 필요적 전치주의를 규정하는 경우가 있다. 이러한 법률 규정은 행정소송법 제18조 제1항의 단서 규정으로서 우선적으로 적용된다. 예를 들어 국세 부과 처분에 대해서는 국세기본법 제56조 제2항에 따라 심판청구 등을 거치도록 규정하며, 공무원에 대한 징계 등 불이익 처분에 대해서는 국가공무원법 및 교육공무원법 등에서 소청심사 등을 필수적으로 거치도록 한다. 도로교통법 제142조 역시 운전면허에 관한 처분에 대하여 행정심판 또는 이의신청을 거치도록 규정한다.

3. 무효확인을 구하는 취소소송

- 무효등 확인소송에는 행정심판전치주의가 적용되지 않으나, 처분의 무효를 구하는 의미의 취소소송에 전치주의가 적용될 것인지에 대하여는 학설이 대립한다. 판례는 행정처분의 당연무효를 선언하는 의미에서 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하는 경우에는 전치절차와 그 제소기간의 준수 등 취소소송의 제소요건을 갖추어야 한다고 판시하여 긍정설의 입장이다.

4. 제3자효 행정행위

- 제3자효 행정행위에 대하여 그 행정행위로 인해 자신의 권리 또는 이익이 침해된 제3자가 제기하는 취소소송은 통상의 취소소송과 동일한 성격을 갖는다. 따라서 해당 처분이 개별 법률상 필요적 전치주의 적용 대상인 경우에는 제3자에게도 전치주의가 적용된다. 다만, 제3자는 처분 사실을 알기 어려울 수 있으므로, 심판 청구 기간 준수 등 요건 완화의 필요성이 있다. 판례는 일반적으로 제3자효 행정행위에 대해서도 필요적 전치주의의 규정이 적용된다고 본다.

5. 2단계 이상의 행정심판절차가 규정되어 있는 경우

- 관계법령이 하나의 처분에 대하여 2단계 이상의 행정심판절차를 규정한 경우에는 당해 절차를 모두 거치게 한다면 제소자에게 과도한 부담을 줄 수 있으므로 명문의 규정이 없는 한 그중의 하나만 거치면 행정심판전치주의의 요건은 충족된 것으로 보는 것이 학설의 일반적 태도이다.

IV. 행정심판전치주의의 적용 제외

1. 행정심판의 재결 없이 행정소송을 제기할 수 있는 경우[행소법 제18조 제2항]

- 행정소송법 제18조 제2항은 행정심판을 청구했더라도 재결 없이 소송을 제기할 수 있는 경우를 규정한다.

(1) 재결을 거치지 아니하면 회복하기 어려운 손해 발생 우려

- 행정심판 절차를 거치는 동안 시간적 지연으로 인해 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있고, 그 손해 방지를 위해 긴급한 필요가 있는 때에는 재결 전이라도 소송을 제기할 수 있다.

(2) 법령에 의한 행정심판기관의 의결 또는 재결을 하지 못할 사유가 있는 때

- 행정심판기관이 사정 변경 등으로 인하여 사실상 기능을 상실하거나 법률상의 이유로 의결 또는 재결을 할 수 없는 경우 등이 이에 해당한다.

(3) 그 밖의 정당한 사유가 있는 때

- 행정심판 청구 후 상당한 기간이 경과하도록 재결이 없거나, 재결의 기대가 불가능한 경우 등 위의 사유에 준하는 정당한 사유가 있는 때이다.

2. 행정심판의 청구 없이 행정소송을 제기할 수 있는 경우[행소법 제18조 제3항]

- 행정소송법 제18조 제3항은 행정심판 청구 자체를 하지 않았더라도 소송을 제기할 수 있는 경우를 규정한다.

(1) 동종 사건에 대하여 이미 기각재결이 있는 때

- 동일한 당사자가 아니더라도 동일한 사실 관계를 가진 사건에 대하여 이미 적법한 행정심판 절차를 거쳐 기각재결이 있는 때에는 행정심판 절차의 반복 낭비를 피하기 위해 전치 요건이 면제된다.

(2) 사실심 변론종결 후 처분을 변경한 때

- 원고가 소송을 제기한 후 피고 행정청이 당해 처분을 변경하는 처분을 하였을 때 원고가 그 변경된 처분을 다투기 위하여 소 변경을 하는 경우에는 소송 경계를 고려하여 변경된 처분에 대해 별도의 전치 절차를 요하지 않는다.

(3) 피고가 행정심판을 거칠 필요가 없다고 잘못 알린 때

- 피고 행정청이 원고에게 행정심판을 거치지 않고 바로 소송을 제기할 수 있다고 잘못 안내한 경우, 원고의 신뢰 보호를 위해 전치 요건이 면제된다.

V. 행정심판전치주의의 이행 여부의 판단

1. 적법한 행정심판청구

- 전치주의의 이행 여부는 원칙적으로 당해 처분에 대한 적법한 행정심판 청구가 있었는지 여부로 판단된다. 부적법 각하재결이 나온 경우 전치 요건은 미충족된다. 다만, 행정심판기관이 본안 심리를 실질적으로 행하여 기각 또는 인용 재결을 한 경우에는 설령 청구 절차가 다소 흠이 있었더라도 전치 요건이 충족된 것으로 본다.

2. 직권조사사항

- 행정심판전치주의는 취소소송의 소송요건에 해당한다. 소송요건은 법원이 직권으로 조사하여 판단해야 할 사항이므로, 법원은 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 행정심판 청구 및 재결의 존부, 적법성 등을 조사해야 한다. 전치 요건이 결여된 경우에는 법원은 취소소송을 각하해야 한다.

3. 판단의 기준 시

- 행정심판전치주의의 이행 여부는 사실심 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 이는 전치주의의 요건 충족 시기에 관한 판단과 동일하다. 따라서 원고가 소송 제기 이후에라도 사실심 변론종결 전까지 적법한 재결을 받는다면 전치 요건은 충족된 것으로 보아 소송은 적법하게 된다.

VI. 결론

- 행정심판전치주의는 취소소송의 소송요건 중 하나로 필요적 전치 규정이 있는 개별 법률에 한하여 적용된다. 현행법상 임의적 전치주의가 원칙이므로, 필요적 전치주의가 적용되는 경우 적법한 심판 청구가 있었고 재결을 거쳤는지 여부는 소송 적법성 판단의 핵심이다. 전치주의는 행정 자율성 존중 및 사전 권리 구제라는 목적을 갖지만, 긴급한 상황이나 소송 경계 등을 고려하여 다양한 적용 제외 규정을 두어 국민의 재판 받을 권리를 실질적으로 보장하고 있다.